Resumen – Aspectos Legales y Profesionales – 2do Parcial – Ingeniería

Licenciamiento de uso

Contratos sobre software

Si queremos darle el software a un cliente por un requisito económico necesitamos las formar contractuales en que podemos hacerlo. Hay algunas formas básicas:

- Puede ser la compra/venta de sistemas de hardware.
- Existe el licing de sistemas de información: en este caso el activo pasa a ser un pasivo, lo que permite descontar impuestos y reducir balances. Es más barato que una compra/venta.
- Hay dos tipos de contratos básicos, cuál de los dos conviene depende del negocio o el mercado potencial del programa:

Cesión de Derechos (Ley 11723)

- Prevista por la ley 11723, dice que se pueden ceder derechos de explotación económica a cualquier tercero a partir de las reglas comerciales.
    - Esta modifica la titularidad del software.
        - Este negocio jurídico hace que la explotación del sistema de software pase al cliente.
        - Puede ser total o parcial.
        - Acompaña a todo lo relativo al programa.
            - Se acompaña al código objeto, el código fuente y la documentación de desarrollo ya que el cliente puede modificar el producto
- Es preferible si tenemos un mercado más bajo, ya que se cobra más y se ahorra el mantenimiento.
- El contrato de licencia es un contrato innominado, dependiendo su contenido de las estipulaciones establecidas por las partes

Licencia de uso

- La titularidad del programa no cambia
- Se entrega el derecho al uso y goce del programa (a los términos de la licencia).
- Un software licenciado permite solamente ciertos usos, los cuales varían de licencia a licencia.
- Esta opción es preferible si existen más clientes.
    - Puedo revender, pero gano menos.
- Dos tipos básicos:
    - Licencia propietaria:
        - No se tiene acceso al código fuente
            - Dificulta el mantenimiento.
            - Se puede resolver con los contratos de mantenimiento
                - Ejemplo: mesas de ayuda.
                - Cualquier cosa se denomina contrato de mantenimiento luego de la entrega.
                - Suele ser costo oculto, hay que definirlo de entrada
                - Representa un costo al cliente.
        - Está prohibido la retroingenieria.
        - Puede ser a título gratuito u oneroso.
    - Licencia no propietaria:
        - Permiten al acceso al código fuente, pero no son dominio público, el software sigue teniendo un autor.
        - También pueden ser gratuitos u onerosos.
        - Este tipo de contrato se empieza a desarrollar con Unix ya que todos querían tomarlo como propietario al ser parte del dominio público y se resuelve al escribirse la GPL.

GPL y OSF

- El término Software Libre tiene su origen en el manifiesto producido por Richard Stallman conocido con el Manifiesto GNU.
- Desde el punto del licenciamiento, Stallman introduce la licencia GPL:

    - Plantea un cambio en los derechos de los desarrolladores para asegurar que los usuarios puedan usar, copiar, compartir, estudiar, modificar y mejorar el software libremente.
    - Stallman dice que todas las personas tienen el derecho de conocer que están usando.
    - Tiene licencia oficial.
- Eric Raymond argumenta que el acceso libre al código fuente mejora la calidad del software y critica la GPL por ser demasiado restrictiva, prefiriendo el término "open source software" (OSF) para enfatizar aspectos técnicos.
    - OSF no establece licencias obligatorias, sino que hay certificaciones.
    - Raymond dice que debe haber gente para desarrollar programas, no debe haber limitaciones contractuales.
        - Es preferible que haya una gran comunidad por lo que se debe hacer fácil el acceso.

Propiedades de GPL

Sus propiedades son las siguientes:

- Ejecución absolutamente libre.
    - No implica la aceptación de licencia.
- Derecho a distribuir el software incluso a título oneroso.
    - Las obligaciones (y limitaciones) empiezan con la distribución.
    - Si es a título oneroso conviene ofrecer algo más que no tienen las gratuitas.
    - Excepcionalmente, permite la entrega material del programa a terceros:
        - Siempre y cuando los mismos actúen por órdenes y en beneficio exclusivo del usuario. En este caso no es posible hablar de distribución.
- Derecho a modificar el software.
    - La modificación autoriza trabajos derivados del original.
    - Si se trata de la distribución de un programa modificado se debe establecer autoría y cuál es el software original.
    - El programa modificado debe distribuirse como un todo bajo la licencia GPL.
    - Se puede incorporar código de otro programa.

- Copyleft: se pueden modificar programas pero no la forma de licenciamiento.
    - Debe seguir siendo GPL.
        - Aún en los casos en que el programa se encuentre compuesto por elementos con otras licencias.
        - Si se incorporó en el programa fragmentos de código licenciados en GPL también se debe licenciar en GPL.
    - Con copyleft si una librería esta licenciado en GPL, el programa que la llama (no importa si en realidad no se está incorporando un fragmento de código) debe estar licenciado también en GPL. No hay licenciamiento autónomo. Esto de llamadas se estableció en GPLv3, en GPLv2 realmente no estaba previsto.
- Obliga a poner a disposición el código fuente de forma gratuita.
    - GPL no puede cobrar por acceso al ejecutable y también por el fuente. GPL no obliga a acompañar con el fuente, lo que no se puede es cobrar más por el acceso al código fuente.

LGPL

- LGPL limita el copyleft en las llamadas:
    - Si una librería esta con LGPL, el que la llama puede usar otra licencia.
        - Hay licenciamiento autónomo.

GPLv3

- La licencia no se actualiza automáticamente cuando hay otra versión.
- Con la salida de la versión 3 hay un quiebre en la comunidad.
- Es la que dice que si hay código embebido de GPL en el programa este se debe licenciar bajo GPL.
- Cuando se acepta la GPLv3 se está dando un acuerdo de patentes a todos los que aceptaron la licencia. Básicamente se renuncia a patentes.
- Los DRM y los Anti-DRM son legales.
    - DRM chequea si hay copyright.

- Se puede tener un DRM en Linux pero se renuncia a demandar a alguien que hace un burlador de DRM.
    - Esto se sostiene con que si el sistema tiene casos legales, aunque también los tenga ilegales, este objeto no es ilegal.

Contratos conexos

Mantenimiento

- Celebrados junto o después de la transferencia de titularidad del software o licencia de uso.
- Abordan la complejidad de los sistemas y los riesgos asociados.
- Cobertura desde asistencia ante fallos (mesa de ayuda) hasta actualización de componentes.

Escrow

- Accesorio a otro contrato.
- Variación del contrato de depósito.
- Involucra a la empresa de software (depositante), el usuario y un tercero depositario del código.
- El depositario conserva y entrega el código bajo ciertas condiciones.
    - Entrega el código fuente al usuario si desaparece el depositante.
    - Solo el cliente puede sacarlo y en esas condiciones.
- El depositante no puede sacar el código.

Derecho de Internet

Derecho de Internet

- La Internet representa un cambio de paradigma en las redes, pasando de un mainframe central a una red distribuida.
- Durante la Guerra Fría, EE.UU. distribuyó la información en una red para evitar la vulnerabilidad de los centros de cómputo ante ataques nucleares.
- La descentralización comenzó en EE.UU. con la "Galactic Network" y llevó a la creación de ARPANET.

- Internet se originó en ARPANET como herramienta militar y luego fue adoptada por universidades para intercambios científicos.
- En 1986, la gestión de la red pasó a la Fundación de Ciencias, acentuando su cambio de uso.
- En 1995, Internet quedó en manos de la sociedad de Internet, popularizándose con el navegador Navigator y el lanzamiento de Windows 95.
- Es en el 2000 donde se empieza a crear una crisis en el internet dado que se hace más común la comunicación horizontal entre los usuarios. Empiezan a haber portales, foros y otro tipo de interacción que genera problemas jurídicos.
- La respuesta a algunos de estos problemas era el espacio anómico
    - Espacio sin reglas donde no hay soberanía.
    - Esto esconde el existente peso de ciertos países para explotar el espacio de internet sin preocuparse de la soberanía de los países (como sucede en las aguas internacionales).
        - Hay una renuncia en detrimento de individuos o empresas particulares.
    - Ya que el espacio físico no tiene entidad en el ciberespacio las fronteras legales se desdibujan y son difíciles de aplicar.
        - Un cuerpo que establece gobernanza no sirve.
        - La sociedad de internet carece de imperio. No hay un centro generador de normas ni tampoco un “tribunal”. No hay una legislación de Internet. Esto dio lugar a la idea de Internet como un espacio anónimo

        - Hay otra opción para poner reglas → organismo controlador. Si se tiene esto igualmente falta que juez para entender y con qué va a resolver.

Normativas Básicas en Internet

Para responder, el Estado debe solucionar: cómo asignar la competencia de ley aplicable, qué juzgado tiene que intervenir y cuál es la ley que se va a usar para solucionar el problema.
En Internet un paquete puede pasar por múltiples servidores. Esto genera infinitos lugares donde se puede asignar la competencia

- El domicilio de autor
- El servidor
- Domicilio de la víctima
- Domicilio de cada uno de los sujetos que acceden al archivo
- Lugares por donde pasa el mensaje
    - Ahí se tienen muchísimas competencias diferentes

Para establecer las normativas básicas:

- Se podría sacar del medio los lugares contingentes de la información (por donde pasa el paquete)
    - No cambia nada desde el punto de vista jurídico.
    - En este caso queda con el lugar el autor, la víctima, el servidor o los efectos (quien lo vio).
- En principio se puede usar el lugar del servidor como ley aplicable. Esto genera un problema debido a la:
    - Existencia de servidores de conveniencia: se pueden mover fácilmente, modificando así la ley aplicable.
    - Uso de la nube: dependiendo del sistema utilizado se almacena datos en servidores geográficamente cercanos o los datos circulan permanentemente, en este caso no hay servidor físico, se descorporiza.
    - Por lo tanto usar el lugar del servidor se hace inaplicable.
- Se puede usar el domicilio de la victima
    - Si soy la victima quiero que la ley aplicable sea la de donde estoy.
    - Es el mejor notado a los efectos de asegurar el acceso a la Justicia ya que ahí es donde está el damnificado.
    - El problema es que en muchos casos no se tiene efectos en el domicilio de la víctima ya que el hecho ocurre en otro lado.
    - Teoría de Long Arm:
        - Teoría para habilitar la competencia en el domicilio de la víctima.
        - Pide tres requisitos:
            - Un daño: en el domicilio del demandante (victima)
            - Un beneficio: económico obtenido por el demandado del ilícito cometido.
            - La previsibilidad: el beneficio y daño tienen que ser previsibles por parte del autor.

        - El demandado pudo haber previsto el daño.
        - No puede ser una consecuencia remota.

    - Si se dan los tres, se habilita la competencia y la ley aplicable es la de la víctima.

Firma Digital

Forma en la cual se pueden firmar documentos a través de Internet. Es para darle forma a los actos jurídicos en Internet.
Hay que establecer la naturaleza del problema:

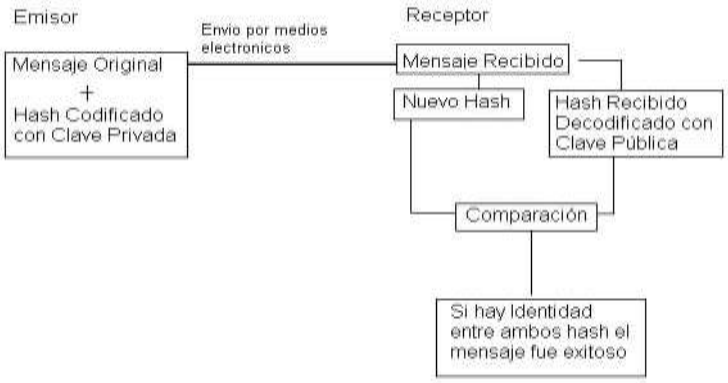
- El problema que se va a tener es la idea de un documento digital:
    - En los documentos públicos y privados hay una serie de seguridades en papel que hacen que no existiera el repudio.
    - El problema con un documento digital es que no se tiene formato papel.
        - La capacidad de modificación del texto hace que sea muy fácil el repudio del documento.
        - Además se hace muy difícil autenticar los documentos. Al no haber un formato en papel, es imposible firmarlos a mano (requisito esencial).
            - Aunque se puede firmar digitalmente, hay problemas:
                - La firma digital no siempre coincide con la firma real.
                - Puede haber una discrepancia entre lo que registra la máquina y lo que se escribe con el dedo.
            - Otra opción es escanear la firma manuscrita y añadirla a un documento como una imagen JPG.
                - Es ineficaz ya que no demuestra autoría, solo prueba la posesión de un JPG.

Solución a los problemas del documento digital

- Criptografía.
    - Se usa un mecanismo criptográfico de clave asimétrica.
        - Hay un problema básico con la criptografía simétrica:

        - La misma clave se usa para cifrar y descifrar, por lo que ambas partes deben mantenerla confidencial.
- En la criptografía asimétrica, se tienen dos claves:
    - En principio una clave que cierra/encripta el mensaje (es publica) y otra que lo abre/desencripta (es privada)
        - Como la clave es pública, no se necesita confiar que el emisor va a guardar el secreto de la clave, y el receptor tendrá privacidad porque ese mensaje sólo lo puede abrir con su clave privada.
    - Esto soluciona la privacidad pero no la autoría.
        - Como la clave es pública, el emisor puede ser cualquiera.
    - Para tener la autoría se debería invertir el aparato
        - Cerrar con la clave privada de A.
        - De esta forma se sabe que el mensaje lo envía A. Se pierde privacidad porque lo puede abrir cualquiera con la clave pública e integridad porque el receptor no puede asegurar que el mensaje haya sido modificado. Y, salvo que exista un acuerdo anterior con el emisor, todavía no es posible determinar quién es el autor.
        - El primer problema se soluciona con la aplicación de un nuevo algoritmo matemático conocido como Hash:
            - Un hash es un número obtenido mediante una operación matemática aplicada a todos los caracteres de un mensaje. Cualquier mínima modificación en el mensaje produce un hash diferente.
            - Se hashea el mensaje y se encripta con la clave privada de A.
            - Se manda a B, él lo recibe (documento y el hash encriptado con la clave privada de A)
            - B hará dos operaciones básicas:
                - Desencriptar con la clave pública de A el hash.
                - Hasheará el mensaje que le enviaron.

- Si estos dos son iguales el mensaje es el mismo.



- Para acreditar la identidad de remitente:
  - Salvo que las personas hayan acordado algo, se necesitaría alguien que informe de que origen es el archivo y con qué clave se va a abrir.
  - Esto se logra mediante un certificado digital.
    - Pieza de un documento digital que se acompaña al documento. Establece es quien es el firmante y cuál es su clave pública de forma tal que se tenga autoría y se pueda abrir el documento.
    - Es emitido por entidades fiscales.
    - Normalmente son terceros (sociedades comerciales en general) que certifican, emiten claves y certifican el estado de las claves.
      - Si fueron robadas, si hay que darlas de baja, etc.

Ley 25506

- Es una ley bastante mala.
- La idea es incorporar los mecanismos mencionados al derecho argentino.
- Salió en 2001, pero se aplicó después de la pandemia.
- Define la firma digital de una forma bastante compleja y deficiente.
  - Cuando uno define cuestiones técnicas en una ley, puede hacer:
    - Una ley que sea tecnológicamente neutra.

        - Usar una definición técnica.
    - La ley junta lo peor de las dos cosas antes mencionadas:
        - Hace que no se pueda no usar criptografía asimétrica.
        - Se aseguro el uso de una sola tecnología a través de una definición bastante mala.
- Prevé dos tipos de firma:
    - Electrónica: la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos usados como identificación, pero no cumple todos los requisitos legales de la firma digital.
        - Es una firma digital a la cual le falta alguno de sus elementos. Por lo que la firma digital es un subconjunto de la electrónica.
        - Primero se tendría que haber definido la electrónica.
            - En los artículos 2 y 3 se define firma digital, y recién en el 5 se define la electrónica.
    - Digital: explicado más arriba.
    - Ventaja de la digital sobre la electrónica:
        - Presunción de integridad del documento.
        - Presunción de autoría del documento:
            - Si se tiene una firma digital y se presenta en juicio, y la otra parte la desconoce, es esta la que tiene que probar lo que dice.
            - En términos reales la firma digital tiene un nivel de seguridad mayor a la ológrafa.
- Establece la equivalencia entre el documento papel y el digital:
    - Cuando la ley u ordenamiento jurídico exige forma escrita, se puede usar formato papel, o se puede usar documento digital con firma digital
        - Hubo debate porque inicialmente la ley no mencionaba específicamente la firma electrónica lo que genero discusiones.
        - Posteriormente, se estableció mediante legislación reglamentaria que tanto la firma digital como la firma electrónica son equivalentes.
        - Hoy, ambas tienen la misma validez y pueden sustituir al formato papel en principio.
- Define los certificados digitales:

- Documento digital que acompaña al documento original, en el cual se dice quién es el titular, cuál es su clave, quien emite el documento, plazo de validez, y también puede haber ciertas reglas respecto al uso.
    - La firma digital puede estar pensada solo para ciertas actividades.
- Estos certificados son revisados por las entidades certificantes.
    - Tienen la tarea de certificar y controlar el estado de estos documento.
    - Solo pueden ser entidades certificantes las personas jurídicas.
    - Pueden ser de:
        - Derecho público:
            - El Estado puede ser certificante.
            - La primera entidad fue el ANSES.
        - Derecho privado.
    - Estas entidades tienen que estar licenciadas por la autoridad de aplicación.
        - Hay una entidad en el Estado a la cual estas entidades le deben rendir cuentas, presentando un expediente y probando que cumplen con la reglamentación vigente respecto a seguros niveles de seguridad, etc.
    - El problema que tuvo esta ley (del 2001), era que nunca se hizo la autoridad de aplicación hasta fines de la década del 2010.
        - Entonces ninguna de las entidades certificantes eran emisoras de firmas digitales.
            - Eran todas emisoras de firmas electrónicas
                - Ninguna estaba licenciada por el Estado.
    - Hoy si hay firmas digitales:
        - Las entidades certificantes extranjeras no están autorizadas por el Estado argentino.
            - Soluciones:
                - Acuerdo por el cual una empresa argentina certificante licenciada reconozca los certificados de una entidad extranjera.
                - Que el país tengas un acuerdo/marco legal con otros países.

Responsabilidad reflejada de los buscadores e intermediarios de Internet

- Responsabilidad de los buscadores:
    - La postura negativa argumenta que los buscadores no tienen control editorial sobre los contenido.
    - La postura afirmativa sostiene que los buscadores obtienen beneficios económicos y deben ser responsables cuando los resultados de las búsquedas causan daños.
- Responsabilidad en el derecho argentino:
    - Jurisprudencia: en casos como el de Virginia Da Cunha y Belén Rodríguez, los tribunales han abordado la responsabilidad de los buscadores por violación de la imagen personal e invasión a la intimidad, con decisiones que varían en cuanto a la necesidad de notificación judicial previa y el rol de los buscadores en controlar los contenidos dañinos.

Comercio Electrónico

- En el comercio electrónico algo fundamental es reducir costos.
- El concepto es de marketing o económico. Esto le da cierta complejidad.
- Por lo tanto el comercio electrónico tiene muchas definiciones:
    - Una definición puede ser el intercambio de datos con un contenido económico. Algunos plantean que todo se da en la red. Esto deja afuera algunos contratos, por ejemplo la compra de algo físico. Además agrega contratos conexos como por ejemplo importaciones de aduana.
    - En algún momento la definición vino de la mano del ministerio de economía, diciendo que es el simple intercambio electrónico de datos con carácter económico. Esto último es laxo ya que mete cosas que no son las que se piensan cuando se habla del concepto, por ejemplo el E.D.I
- Cuando se hable del comercio electrónico se estará hablando del intercambio electrónico de datos que se produce en redes abiertas como por ejemplo internet.

Problemas

- Competencia y ley aplicable:
    - Hay una contraposición de dos intereses jurídicos defendibles:

- Mas que nada en B2C (business to consumer)
    - Interés del consumidor que su domicilio sea donde ocurre el conflicto.
    - Empresa quiere calcular costos y que no denuncien desde cualquier lado.
- Esto es más que un problema jurídico.
- Solución:
    - <u>Principio general:</u>
        - La competencia y ley aplicable por lugar de ejecución del contrato.
        - Surge otro problema: puede haber más de un lugar de ejecución.
            - Como solución a esto se elige el más característico (es el que siempre varia).
            - El pago del precio es siempre el mismo, por lo que este no es el más característico, si no que el más característico es la otra obligación.
            - Entonces, es más definitorio el cumplimiento de la otra contraprestación
            - Entonces no interesa donde se paga el precio, sino donde se paga el bien (eso sería en Argentina, el lado del cliente).
            - Entonces en principio para la ley argentina el lado más característico es el del cliente.
    - <u>Prorroga de competencia:</u>
        - Es un pacto en donde ante conflicto se pacta que se maneja con la competencia de tal lado.
        - Cuando se está en una relación de comercio electrónico de business to business estos pactos son válidos.
        - En relaciones de consumo (B2C) son inválidos, pero EE.UU las permite.

            - El problema es cuando el contrato se ejecuta en el exterior. Por ejemplo si se hace de Argentina con EE.UU acá es invalido y allá es válido.
            - Esto plantea un problema porque se va a necesitar un juez norteamericano que admita que la sentencia argentina es válida (el pacto no es válido), y esto no va a suceder porque para él es invalida la argentina (el pacto es válido).
        - Una solución que estable la UE es el derecho comparado:
            - Si la empresa esta activamente en la búsqueda de cliente entonces el pacto es invalido.
            - Si la empresa simplemente admite la compra desde algún país determinado, teniendo una actitud pasiva, el pacto es válido.
- Manifestación de voluntad:
    - Como se acepta sin firma digital normalmente se tiene contrato de adhesión:
        - Internet Agreements:
            - No se usan estos.
            - El hecho de contactarse y bajar el programa implica la aceptación de términos y condiciones.
            - Problemas:
                - No se leen los términos.
                - Se le está dando carácter de acto jurídico a algo que no lo es ya que no se quiere generar una relación jurídica. No se quiere celebrar un contrato se quiere bajar un programa.
        - Click and Warp Agreements:
            - Hay interacción con cuadro de dialogo:

        - **Click:** en aceptar
        - **Warp:** la validez del acuerdo tiene un límite. Si no se tiene acceso real a los términos la aceptación es viciada.

- Medio de pago:
    - SSL: es el protocolo de seguridad. Operatoria entre página y cliente. En este caso se olvida la empresa gestora de tarjeta de crédito que puede rechazar luego de la facturación. La solución es pedir autorización a esta antes de dar el OK.
    - APP: Fintech o dinero electrónico.
        - No es lo mismo usar cuenta DNI (Fintech) que Mercado Pago o UALA (dinero electrónico):
            - Cuenta DNI representa un contrato bancario. Atrás de la aplicación hay un banco ofreciendo un servicio de pago. Si se quieren los datos hay que levantar el secreto bancario.
            - En el caso de Mercado Pago o UALA son empresas no respaldadas por bancos. Son una billetera virtual en donde cualquier abogado puede pedir los datos.
    - Criptoactivos: es una red autónoma basada en criptografía que se maneja por consenso.
        - No está respaldado por nadie, no tiene emisor como por ejemplo la Argentina con el Banco Central. Tener esto último implica un riesgo de pérdida de valor relacionado con el aumento de la emisión. Por lo tanto se evita esto último realizando un sistema que no necesite regulación del estado.
        - Se maneja por concenso, al contrario de los tradicionales que son fiduciarios (hay 3ro que da fe de operaciones). La fe en el caso de los criptoactivos se produce por el propio sistema. La misma red de blockchain va validando.
        - Se trata de mantener la escases de la moneda para que sea reserva de valor.
        - Hay anonimato: los criptoactivos están vinculados a la billetera virtual, no a la persona.
        - Puede haber problemas de lavado:

- En el lavado el problema es sacar la plata, es difícil hacerlo. Como las bitcoins son descorporizadas se hace fácil esto último. Se pueden mover virtualmente y las operaciones son anónimas.
- Para solucionar esto se usa el KNOW YOUR CLIENT de los bancos, en donde hay un tercero que controla. En el caso de los criptoactivos esta obligación se expande a quienes hacen trading de los activos. Se los obliga a cumplir estándares de control que cumple por ejemplo alguien que vende acciones.
    - Esto sigue teniendo problemas porque en los criptoactivos no necesariamente hay que pasar por un trader.
    - Además los traders se pueden cambiar a lugares grises. Para esto último no hay mucha solución puesto que los países que impulsan estas medidas son los países más grises en términos de colaboración de información financiera.
        - No está penada la evasión fiscal que usa los mismos medios de lavado de crimen internacional.

Bancos de Datos

Banco de Datos

- Esta muy vinculado al concepto de la intimidad/privacidad
- Un banco de datos es un sistema organizado que permite guardar o recuperar información, puede ser informático o en formato papel.
- Cuando se tiene un gran banco de datos la información empieza a ser económicamente valiosa y puede intimidar la privacidad de las personas.

- Surge el problema de cómo regular el manejo de datos para asegurar la intimidad y privacidad de las personas.

Privacidad e intimidad

- Son conceptos relativamente nuevos.
- <u>Limites en el Art. 18 de la CN:</u>
    - Inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y los papeles privados:
        - La comunicación privada no puede ser discutida por el estado.
        - Cuando se habla de correspondencia es sobre cualquier medio, la protección se extiende a las comunicaciones electrónicas.
            - Si algo es de origen ilícito no se puede usar.
                - Si la información es leakeada y la uso es discutible.
        - No es lo mismo si una de las dos partes filtra la información.
        - Esta garantía desaparece cuando hay una orden de un juez competente.
- <u>Limites en el Art. 19 de la CN:</u>
    - Principio de privacidad:
        - Las acciones privadas de los hombres que no afectan a terceros quedan afuera del poder de los magisterios.
        - Este concepto empieza a quedarse obsoleto mientras avanza la sociedad.
- <u>Limites en el Art 1071 Bis:</u>
    - Trata sobre el derecho de todas las personas a ser dejados solo (no querer compartir).
    - Los terceros no pueden violar la esfera y compartir la información.
    - Establece la responsabilidad de las personas que se entrometen de forma ilícita en la intimidad de las personas.
- <u>Limites en el Art. 43 de la CN (1994):</u>
    - Principio de Habeas Data.
        - Es un paso más.
        - Protege información personal de la gente.
    - No diferencia entre datos íntimos y no íntimos.
        - Ambos deben estar protegidos.
    - El derecho que se protege no es solo a la intimidad, sino también la autodeterminación informativa.
        - Si soy dueño de la información, yo defino si quiero o no compartirla.
    - Se consagra con la ley 25326.

Ley 25326

- Es la ley de banco de datos.
- Se crea dado a regulaciones internacionales para proteger la información personal que obligaban a registrar todos los bancos de datos.
- Muy poca gente registra los bancos de datos, ya que nadie controla.
- Ámbito de aplicación:
    - Se aplica solamente a aquellos bancos de datos personales que están destinados a brindar informes.
        - Un dato personal: cualquier dato que se pueda vincular a alguna persona física o jurídica.
            - No incluye:
                - Los datos de la naturaleza: terrenos suficientemente grandes, animales que no están relacionados a ningún dueño (si se incluye dueño es personal).
                - Leyes especiales: datos que tengan un régimen particular como el registro de reincidencia penal.
                - Fuentes periodísticas.
                - Los datos disociados: un dato que en principio es personal pero que por el tratamiento o recolección se rompe vinculación con el titulas, como por ejemplo los datos estadísticos.
        - Destinados a brindar informes: cualquier dato que pueda ser consultado por un tercero como datos de facturación de empresas, consumos de tarjeta, etc.

Clasificación personales

- Datos mínimos de identificación:
    - Son de libre acceso: ej. datos que figuran en el padrón.
    - Son libremente recolectables: siempre que no los entrecrucen.
    - Los datos que nos identifican.
- Datos Sensibles:
    - La ley hace enunciación que son aquellos que den lugar a información sobre la orientación sexual, orientación política, religioso.

        - Algo potencialmente discriminatorio
    - No se pueden recolectar, acceder o tratar (si no es estrictamente necesario).
    - Los datos de deuda o condición de deudor no son sensibles (son de acceso restringido).
- Datos de acceso restringido:
    - Son datos que quedan entremedio de las otras dos categorías antes mencionadas.
    - Se pueden tratar y recolectar en los términos establecidos por la ley de banco de datos.

Principios de Recolección y Tratamientos

De los datos de acceso restringido:

- Licitud y buena fe:
    - Autorización:
        - Prohibido que los titulares de datos recolecten información de manera oculta.
            - Deben ser autorizados por el titular de los datos en forma escrita (papel o digital).
                - La autorización es libre y voluntaria.
                - El consentimiento tiene que ser informado al titular de los datos.
                - Y las características de la recolección de los datos deben ser comunicadas (que datos, quien tiene acceso, etc.)
    - Cesión y tercerización:
        - La autorización para recolectar los datos no implica el poder para cederlos, se debe pedir otra confirmación e informar a quien se cede los datos, en qué términos, etc.
        - Tercerización ≠ Cesión:
            - En la tercerización hay gente que recolecta los datos pero para el tratamiento se contrata a terceros para reducir los costos de la empresa.

            - No se considera una cesión ya el sujeto trabaja bajo orden.
            - En cesión el tercero puede hacer lo que quiera con los datos, en tercerización no.
    - Excepciones:
        - A veces no se pide autorización porque se entiende que la celebración del contrato implica el acceso a los datos para su cumplimiento.
            - Ejemplo: tarjetas de crédito, planes de celular, etc.
            - Caso especial son los informes comerciales (veraz). Estos no están dados por los deudores y estos mismos no autorizan.
                - Están acá por la estructura de obligación, se tienen dos titulares, el deudor y el acreedor, por lo que es de ambos el dato y quien lo cede es el acreedor.
- Pertinencia:
    - Publicidad:
        - Limitación del titular del banco de datos al momento de tratar el dato. Solo puede ser tratado en los términos y condiciones.
- Calidad:
    - Los datos deben mantener una calidad mínima, no pueden ser falsos, desactualizados, incompletos. Deben reflejar la realidad, si no lo hacen el titular de los datos puede rectificar.
        - Datos falsos: no coinciden con la realidad, es sencillo de establecer la falsedad. Se pueden desestimar contrastando con pruebas de la realidad.
        - Datos desactualizados: sucede lo mismo que los falsos. En este caso, estos datos algún vez fueron ciertos.
        - Datos incompletos: son más complicados ya que se puede entender que todos los bancos de datos son incompletos porque solo son representaciones de la realidad (generalizaciones). Hay información que no se pone y que da falsa representación de la realidad, pero en si los datos que se tienen no son falsos.

            - Se debe evitar la pérdida de contextualización para no generar disidencias entre lo entendido por el dato y la realidad. Se deberá discutir que es lo esencial o que no.
- Confidencialidad:
    - Los datos no pueden ser divulgados a terceros.
    - Esta obligación queda en cabeza de cualquier persona que tuvo contacto con estos datos (personas que trabajan en la recolección y tratamiento).
    - Responsabilidad civil en cadena:
        - Todos los sujetos en contacto con la información son responsables.
    - Puede haber responsabilidad penal.
- Derechos del titular:
    - El titular es aquella persona a la que refiere el dato. No hay propiedad sobre un dato, si no que el titular tiene un derecho personalísimo que es extrapatrimonial y en caso de muerte no se trasmite.
    - Derecho de acceso:
        - Toda persona tiene derecho a controlar la información respecto de si misma, de forma gratuita y mínimo cada 6 meses.
        - Se tiene que informar la existencia de los datos con cierto limite.
    - Derecho de control: toda persona tiene derecho a controlar sus datos.
    - Derecho de rectificación:
        - Si se descubren datos falsos, desactualizados, ilegales o incompletos el titular puede pedir el cambio, completitud o destrucción.
        - Existen límites para esto:
            - Legitimación activa: quién lo puede pedir.
            - Datos de terceros: los datos pueden estar parcialmente restringidos si involucran a un tercero.
            - Objeto de la requisitoria:
                - Informar constancias que existen en el archivo
                - Solo hay que volcar constancia no es obligatoria la investigación.
                - La ley establece que en 10 días hay que contestar la requisitoria

- Es necesario usar un medio que acredite la presentación y si se tuvo respuesta o no.
- Si no se responde queda habilitada la garantía de Habeas Data. Esta última no discute la indemnización, solo discute el derecho.
    - La indemnización es por juicio separado de daños y perjuicios.

Responsabilidad de los Titulares de Bancos de Datos

Concepto

- La gestión de un banco de datos y la violación de la ley pueden conllevar responsabilidades:
    - Administrativas
    - Civiles.
    - Penales.
- Pueden aplicarse juntas o por separado,
- Para asegurar la coherencia jurídica:
    - El principio de seguridad establece que un hecho probado en el ámbito penal debe ser reconocido en el civil.
    - Para asegurar esto último, el artículo 1101 plantea que el proceso civil no puede concluir hasta que termine el proceso penal.
        - Las conclusiones del ámbito penal sobre los hechos son vinculantes en el civil.
            - Igualmente el juez civil no puede meterse en lo que se definide en sede penal.

Responsabilidad Administrativa

- El derecho administrativo sancionatorio solo busca el correcto funcionamiento de la gestión pública y las sanciones administrativas son de menor gravedad que las penales.
- El artículo 31 de la ley de bancos de datos establece las siguientes sanciones:
    - Apercibimiento.
    - Suspensión.

    - Multa hasta cien mil pesos.
    - Clausura o cancelación de la autorización de la base de datos.
- Las causales de responsabilidad administrativa:
    - No están específicamente establecidas en la ley.
    - De esta manera queda en cabeza de la autoridad de aplicación crear infracciones y sanciones mediante resoluciones reglamentarias.
        - Hay una crítica por parte de autores. Aun así por la naturaleza del derecho administrativo y la complejidad técnica y cambiante del tratamiento de datos justifica la delegación en la autoridad reglamentaria.
- Reglamentación:
    - Establecen categorías de faltas administrativas.
    - Fijan parámetros mínimos y máximos de las sanciones.
    - Sujetos sancionables:
        - No diferencia entre bases públicas o privadas.
        - Incluye tanto a titulares del banco como a usuarios.
        - Multas improcedentes para bancos de datos públicos.
- Procedimientos:
    - Iniciación:
        - De oficio o por denuncia.
        - Denunciantes: defensor del pueblo, asociaciones de consumidores y particulares con interés particular.
    - Limitación de denuncias:
        - Requiere legitimación activa de particulares.
        - Denunciante no es considerado parte una vez iniciado el procedimiento.
        - Necesidad de un interés legítimo en los hechos denunciados.
- Sanciones:
    - Faltas leves:
        - Multa de mil a tres mil pesos.
        - Posibilidad de 2 apercibimientos.
        - Son infracciones formales, como ausencia de inscripción del banco de datos.
    - Faltas graves:
        - Multa de tres mil a cincuenta mil pesos.

        - 4 apercibimientos y/o suspensión de hasta 30 días.
        - Son incumplimientos formales agravados por reticencia del titular del banco.
    - Faltas muy graves:
        - Multa de cincuenta mil a cien mil pesos.
        - 6 apercibimientos, suspensión hasta 365 días y/o clausura del banco de datos.
        - Son tratamiento ilegítimo de datos, violación de garantías constitucionales, tratamiento de datos sensibles, cesión ilegítima de datos y transferencia a terceros países sin protección adecuada.

Responsabilidad Civil

- Finalidad: indemnizar los daños sufridos por terceros, no sancionar administrativamente.
- Iniciativa: la acción está en manos de los particulares, no del estado.
- Ámbito: relación de derecho privado, con intervención del estado para brindar justicia.
- Régimen aplicable según la naturaleza de la responsabilidad:
    - Responsabilidad contractual:
        - Hay una autorización para uso de datos.
        - El incumplimiento de las condiciones y daños son los extremos a probar.
        - El Autor del daño debe probar causal eximente.
    - Responsabilidad extracontractual:
        - Mas complejo ya que no hay una relación contractual entre el damnificado (quien sufre el daño) y el autor del daño.
        - Dos posturas entre autores:
            - Subjetiva: requiere probar la culpa o dolo del autor del daño.
                - El problema principal es la dificultad de probar la culpa o dolo.
            - Objetiva: no se necesita probar la culpa o dolo; la responsabilidad se establece por otros factores externos.
                - Los daños se clasifican en:

            - Daños por vicios de las cosas (defectos de fabricación, conservación, uso).
            - Daños por peligro innato en las cosas (objetos peligrosos como automóviles o motosierras).
            - Daños producidos con cosas (objetos no peligrosos pero utilizados de manera ilícita).
        - La mayoría de los autores y la jurisprudencia tienden a favorecer la responsabilidad objetiva para proteger al damnificado.
- Elementos constitutivos de la responsabilidad:
    - Obrar antijurídico:
        - La violación de preceptos de la ley y normas generales del derecho civil constituye un accionar antijurídico.
    - Daño:
        - Es el menoscabo en bienes vitales, propiedad o patrimonio. Se incluyen perjuicios económicos o personales.
        - Daño fundamental para determinar la responsabilidad legal y la indemnización.
        - Daño moral: reparación de sufrimientos o molestias no económicas. Su cuantificación queda a discreción del juez.
    - Relación de causalidad:
        - El daño debe ser una consecuencia directa de la acción ilícita para que exista responsabilidad.
        - Solo las consecuencias inmediatas de los actos ilícitos son indemnizables.
    - Imputación de responsabilidad:
        - Determina si la responsabilidad por daños se basa en un criterio subjetivo u objetivo.
- Las cláusulas limitativas de responsabilidad:
    - Es común encontrar cláusulas limitativas de responsabilidad. Su extensión no siempre implica su legalidad.
        - Se distinguen dos situaciones principales:
            - Cocontratante: se está frente a una renuncia anticipada de derechos por parte del titular de datos en beneficio del

titular del banco de datos. La ley de defensa del consumidor realiza una regulación y análisis contractual para detectar aprovechamiento indebido.
    - La nulidad afecta solo la cláusula limitativa, no el resto del contrato
- Reclamos de terceros: las cláusulas no deben impedir acciones de terceros.

Responsabilidad Penal

- La ley de bancos de datos introduce sanciones penales mediante dos artículos en el código penal:
    - Artículo 117 bis:
        - Pena de prisión de un mes a dos años por insertar datos falsos en un archivo de datos personales.
        - Pena de seis meses a tres años por proporcionar a terceros información falsa de un archivo de datos personales.
        - Aumento de la pena si causa perjuicio a persona.
        - Inhabilitación para cargos públicos si autor es funcionario público.
    - Artículo 157 bis:
        - Pena de un mes a dos años por: acceder ilegalmente a un banco de datos personales o revelar información secreta de un banco de datos personales.

Delitos Informáticos

- No es lo mismo un delito informático que uno cometido a través de un sistema de información.
    - Hay delitos tradicionales donde la informática genera nuevos medios para cometerlos.
    - Diferente es que se modifique un sistema informático para que este le mande a un sujeto los medios centavos de cálculos de interés de un banco
- El problema que se va a tener es que los delitos informáticos son cometidos sobre un sistema de información.
    - Este objeto genera una crisis en el sistema penal

- El delito cometido por medios informáticos es un ilícito ya previsto en el código penal, cuya comisión involucra la utilización de un sistema informático.

Ley 26388

Las limitaciones y desafíos que enfrenta el sistema penal al tratar con nuevas formas de delitos facilitados por la tecnología hacen necesaria la incorporación de modificaciones en el Código Penal.

La ley 26388 incorpora delitos informáticos en el Código Penal. No es una ley especial autónoma como la de drogas o la penal tributaria, sino que modifica artículos existentes para adaptarlos a los avances tecnológicos en lugar de crear un nuevo cuerpo legislativo independiente.

Pornografía infantil

- Es el delito informático que más se investiga pero no es un delito informático per se.
- Está relacionado con la pedofilia. Siempre existió.
- Recién ahora hay ley porque la irrupción del internet produjo una serie de cambios que hacen que este problema se agrave con respecto al:
    - Consumo: antes se accedía en cine para adultos o se alquilaba, hoy en día con internet los terceros no tienen la capacidad de saber que se está consumiendo el material pornográfico.
        - Hay mayor facilidad de acceso e intimidad.
    - Grupos de referencia:
        - Permite el contacto entre personas con desaparición de líneas geográficas dando la posibilidad de grupos cada vez más específicos.
        - En estos grupos se puede compartir información, material, consejos para no ser descubiertos, etc.
    - A partir de los 90 empiezan a generarse diferentes legislaciones para combatir esta problemática.
        - <u>Art. 128:</u>
            - Se busca penalizar la distribución y producción de contenido de pornografía infantil.
            - Cubre cualquier tipo de actividad gratuita u onerosa

- Algunos países agravan en oneroso.
- El objeto de esta ley es toda representación de un menor de 18 años con contenido sexual.
    - Representación hace referencia a un hecho ya ocurrido (abuso sexual).
        - Es por ello que los bienes protegidos ya no solo son la integridad sexual (dado que ya sucedió), aunque si tienen caracteres sexuales.

- No incluye actos simulados.
- La pornografía infantil es tecnológicamente neutra.
    - Se puede usar cualquier tecnología.
        - Gran parte en la web era pornografía infantil.
- Tenencia:
    - Originalmente el 2do párrafo del artículo 128 daba una prisión a aquellos que tuvieran en su poder representaciones con fines inequívocos de distribución o comercialización.
    - Esto generaba problemas ya que cuando se habla de pornografía infantil el sujeto se vuelve obsesivo y por lo tanto tiende a acumular y catalogar material .
        - Difícil probar si es para distribuir o consumo.
    - En las redes P2P podes compartir lo que estas bajando y si compartís más de lo que bajas, tenes mayor prioridad
        - Esto hace que el sujeto participe en la red y ahí se sostiene la distribución.
    - Entonces si el sujeto tiene carpetas compartidas, pasa de tenencia a distribución directa
        - Distribuye porque le beneficia.
    - En 2018 se modifica la ley y se incorpora la “tenencia simple de pornografía infantil” con una sanción mucho menor (antes no se había incorporado por el art 19 de la CN).

        - Para que se cumpla el delito el sujeto debe tener un archivo con pornografía infantil.
    - No es federal.

Grooming

- Art. 131.
    - Pena sujetos que por cualquier tecnología de transmisión de datos contacten con una persona menor de edad, con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual del mismo.
- Es un delito doloso.
- Se perfecciona con la mera comunicación.
- Tiene un componente teleológico.

Interrupción de correspondencia

- Delito ya existente pero solo respecto a dos supuestos:
    - Epistolar o interrupción de comunicaciones no digitales con caracteres oficiales.
        - Se podía utilizar gente no oficial para inspeccionar las comunicaciones, por lo que se necesitaba actualizarlo.
- Esto se cambia en el Art. 153 al incorporar comunicación electrónica en el texto.
    - Sus antecedentes son el Art. 18 de la Constitución Nacional.
- Características:
    - Es un delito federal.
        - Competencia del estado central.
    - El acceso debe ser indebido.
        - Quien accede no tiene autorización
            - Esto deja fuera filtro de seguridad.
    - Es tecnológicamente neutra.
    - Si es funcionario público la condena es el doble.
    - No tiene definido los emails laborales.
        - Jurisprudencialmente la cosa fue variando:
            - Muchos fallos admitían que el monitoreo era válido si fue avisado por el empleador.

        - Esto implica una renuncia a los derechos (no se puede hacer)

Acceso no autorizado

- Es básicamente hacking.
- Tiene una figura agravada cuando se accede a un servicio público, sistemas financieros o del estado.
- Se consigue por acceso. Si después del acceso se hace otra cosa es absorbido por otro delito.
    - Esto hace que sea de carácter residual o subsidiario.
- Es el acceso a un sistema restringido.
    - Implica la existencia de algún límite de acceso.
- Debe ser acceso no autorizado.
    - Test y Ethical Hacking no son ilícitos ya que son autorizados.
- No incluye la ingeniería inversa ni la violación de DRM.
    - La ingeniería inversa podría ser violación de propiedad intelectual.

Estafa Informática

- En una estafa se tiene el mismo mecanismo en todos los casos. Hay un ardid que hace que un tercero sufra, en un principio no sufre la victima si no el tercero.
    - Esta la existencia de una persona engañada, un “punto”.
- Sistema del código:
    - Se incorporaron dos artículos.
        - Art.172: Definición genérica.
        - Art. 173: Casos particulares (estafas especificas).
            - Desde el punto de vista de los delitos informáticos nos interesa:
                - El Inc. 16 del Art. 173: Estafas informáticas.
                - En el Inc. 16 no hay un punto.
                - Para que sea una estafa informática debe haber una modificación en el sistema.
- Si se tienen datos falsos esto es Phishing, no es estafa informática.

Daño Informático

- Dos figuras:
    - Se penaliza con prisión de 15 días a un año a quien:
        - Dañe datos, documentos, programas o sistemas informáticos
        - Distribuya código malicioso.
- Es un delito doloso
- Tiene formas agravadas (3 meses a 4 años)
    - Cuando se dirige a autoridades para impedimento o venganza.
    - Cuando recae en sistemas públicos o sistemas de servicio público.

Pericias

Estructura del poder judicial

- Existe un doble sistema judicial, un doble ordenamiento procesal:
    - Federal y Local.
        - Sobre ambos se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Justicia Federal

- Esta es:
    - Excepcional: solo en caso de ley o norma constitucional expresa se habilita esta jurisdicción. Ante la duda siempre se va a lo local
    - Excluyente: los jueces provinciales no pueden entender en estas causas. Los juzgados ordinarios son incompetentes.
    - Improrrogable: salvo por razones personales, no se puede acordar sacar una causa del sistema federal.
- Su competencia abarca:
    - Por materia: causas que versan sobre puntos regidos directamente por la constitución nacional, las leyes federales, los tratados internacionales, aduanas, correo, contrabando, lavado de dinero (dado que es un delito contra el sistema financiero, que es federal), tráfico de drogas, tratas, etc.
        - Cualquier otra causa que no involucre las materias de forma directa, la competencia es provincial.
    - Los sujetos intervinientes: en los casos de causa civil entre los siguientes sujetos.

        - Cuando el estado federal es parte ya sea como demandado o demandante.
            - Si no pagas impuesto federal el juicio de amparo se hace en juzgado federal.
        - Si existen conflictos entre una provincia y:
            - Otra provincia, extranjero o estado extranjero, estado federal, un vecino de otra provincia.
        - También si es un vecino y:
            - Un vecino de otra provincia (puede ser ordinario) o una provincia diferente al domicilio.
    - Por lugar:
        - A pesar de ser materias regidas por el derecho común, es materia federal si los hechos acontecen en territorio con sometido a jurisdicción federal (Ej. Universidades Nacionales).
- El resto es local.

Justicia Local

- Justicia establecida por las provincias.
- Su competencia abarca:
    - Lugar:
        - La provincia de Bs.As. se divide en departamentos judiciales, que abarcan varios partidos/localidades.
        - Los hechos ocurridos en dichos partidos son discutidos en tribunales ubicados en la ciudad sede del departamento judicial.
            - Normalmente se tiene una cabecera del departamento donde van a estar los juzgados/tribunales.
                - A veces para no tener que ir o no depender de la ciudad sede, se tienen fiscalías en los propios partidos.
        - Esta competencia es prorrogable por:
            - Acuerdo de partes.
            - Caso que el demandado no plantee la incompetencia en el juicio.

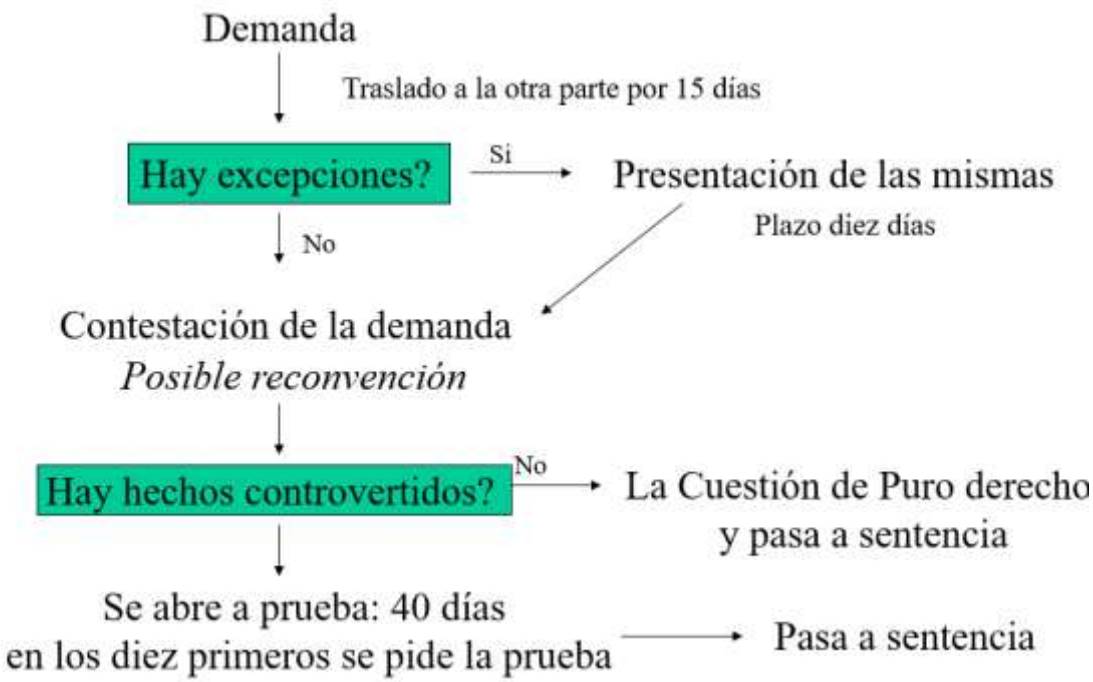
        - Se entiende que en tal caso consiente la radicación en dicho departamento.
    - Materia:
        - Dentro de cada departamento judicial, las causas se dividen en función de la especialización de los distintos juzgados.
        - Existen distintos fueros de acuerdo a las provincias:
        - La competencia por materia es improrrogable.
            - Es decir, por ejemplo, no se puede meter una causa civil en una penal.
        - La competencia se divide en función de grados.
            - Algunos fueros dividen los juzgados en juzgados de 1ra Instancia y Cámaras de Apelación.
            - Por sobre ellas se encuentra la Suprema Corte Provincial.

Proceso

- Conjunto de actos que se definen en función de reglas preestablecidas, que conduce a la creación de una norma individual destinada a regir conducta de sujetos o sujetos.
- Clasificación:
    - Universales: son sobre todo el patrimonio del sujeto
    - Singulares: acá podemos llegar a ser peritos como informáticos.
        - Se clasifican por su contenido:
            - Voluntarios: trámites administrativos. No existe controversia, ni por ende partes en conflicto.
            - Contenciosos: si hay conflicto con otra persona. Siempre hay dos o más partes.
                - Se clasifican por su finalidad:
                - De conocimiento: como sujeto quiero que el juez haga declaración de certeza de algo.
                - Como peritos vamos a trabajar en estos más que nada.
                - De ejecución: buscan un cambio en el estado de cosas.

- Cautelares: buscan asegurar los resultados de un procedimiento posterior. Puede ser el mismo objeto del proceso lo que se quiere asegurar.
    - Ejemplo: en caso de embargo o una medida para asegurar cobro.
    - En estos también podemos aparecer como peritos pero es más raro.

Etapas del Proceso de Conocimiento



La Prueba

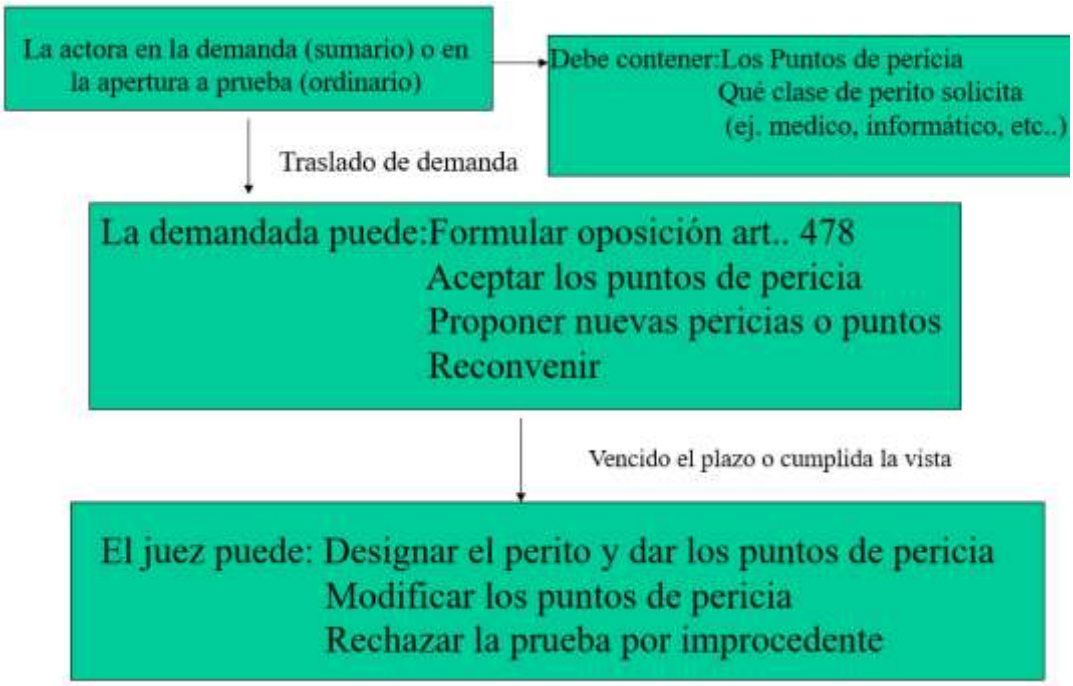
- Todo elemento que proporcione o que tenga poder de convención de la existencia o inexistencia de uno o más hechos.
- Objeto:
    - Recae sobre hechos, no sobre el derecho.
    - Los hechos deben ser controvertidos.
        - No deben ser de algo que ambas partes afirman.
    - Los hechos deben ser conducentes.
- Los pueden solicitar normalmente las partes.

    - Puede existir una excepción donde el juez de oficio pide la prueba y en tal caso se la denomina medida de mejor proveer.
- Prueba pericial:
    - Prueba que se da cuando el juez necesita que alguien resuelva y ese alguien debe ser un experto (es el perito).
        - El juez necesita el conocimiento de un experto.
    - Los peritos son un auxiliar del juez.
- Comparación entre testigo y perito
    - Testigos:
        - Narra lo que percibieron con los sentidos.
        - Los hechos sobre los que declara son anteriores/simultáneos al proceso y son independientes de este.
        - No necesita conocimientos especiales.
        - Es único e irremplazable.
    - Peritos:
        - Formula conclusiones derivadas de la deducción.
        - Los hechos percibidos son posteriores al pleito y ocurren en función de este.
        - Es un experto de la materia.
        - Es remplazable.

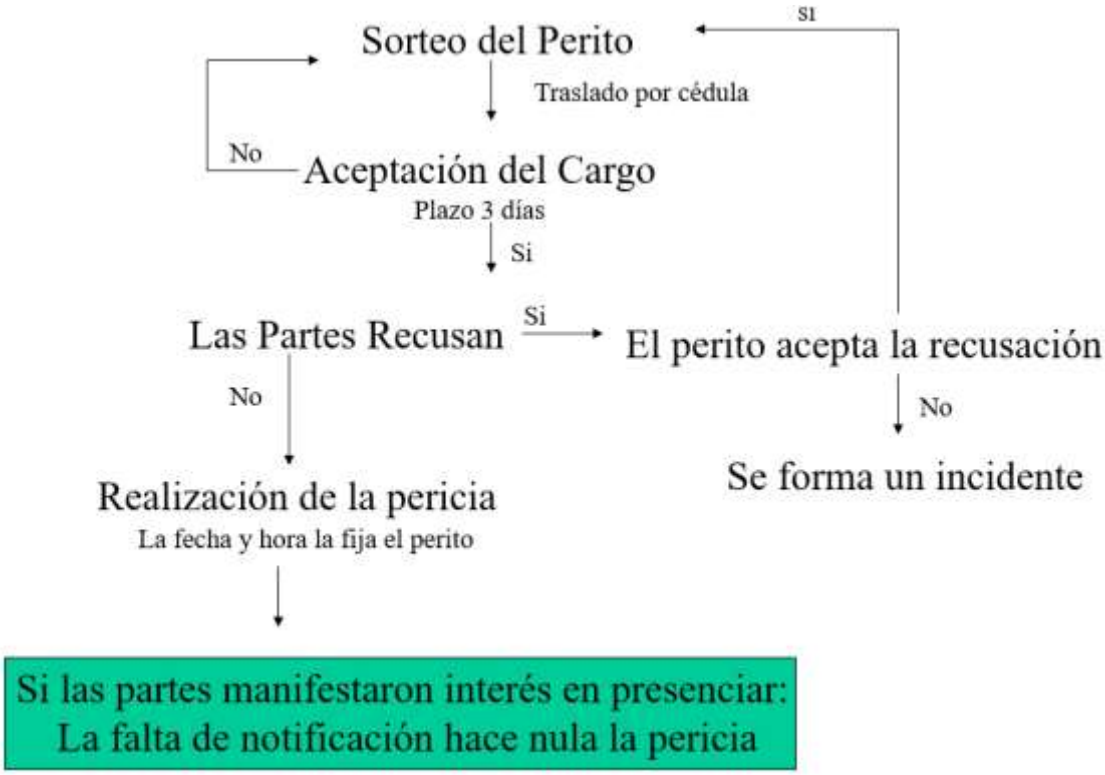
Perito Informático

- En la provincia de Buenos Aires debe tener título habilitante
- Aquellos interesados en cumplir en funciones de perito deben:
    - Anotarse en los listados correspondientes mantenidos por la Cámara de Apelaciones de cada departamento judicial.
    - Tener domicilio en la ciudad donde está el juzgado.
    - Cursar y aprobar los cursos dictados por la Suprema Corte Bonaerense.
- Una vez cumplido estos requisitos el perito ingresa a un listado de su especialidad, del cual es elegido por sorteo realizado por la Cámara.

Preposición de la pericia



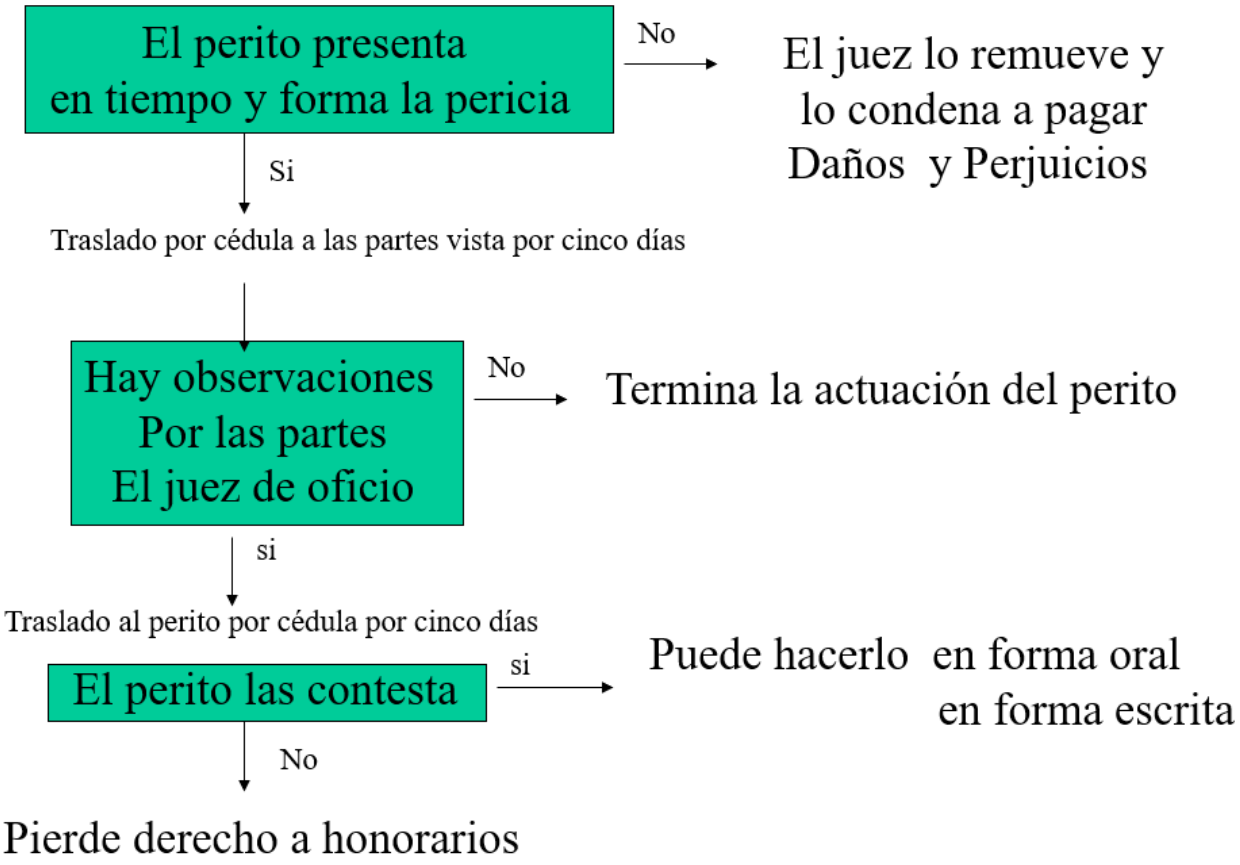
Realización de la pericia



- En el sorteo se da prioridad a peritos no nombrados.
- Hay una obligación de aceptar el cargo.
    - Tiene un plazo de 3 días para responder
    - Si responde que no se saca al perito de la lista por 2 años.
    - Si acepta debe ir al juzgado para hacer juramento.

        - Si mienten, es delito.
- Las partes pueden recusan:
    - Ejemplo el perito es familia de la otra parte.
- Si las partes no recusan se hace la pericia.
    - Antes el perito pide los gastos.
        - Si las partes no pagan, entonces al perito le pagan hasta cierto limite.
        - No se pueden pedir licencias de uso.
    - La fecha y hora la fija el perito.
    - Si las partes quieren presenciar y el perito no notifica la información menester entonces se hace nula la pericia.

Presentación de la pericia



Honorarios

- Se regulan al término del juicio, en el momento de la sentencia, sobre un porcentaje del monto del juicio.
- Están obligados al pago todas las partes.

- Excepción:
    - En el caso que:
        - Una de las partes se haya opuesto a pericia.
        - No haya sido condenada en costas.
        - La pericia no se haya tenido en cuenta al sentenciar.
- Los horarios se pueden apelar, si no depositan en 5 días se inicia un juicio para que la parte pague.
- Justamente no conviene ser perito por los honorarios, puede que no paguen.

Actuación del Perito en campo y laboratorio en Sede Penal

- Usualmente todas las pericias se realizan durante la etapa de Instrucción Penal Preparatoria y se reproducen posteriormente en el Juicio, ya sea mediante lectura o declaración del perito.
- A diferencia del juicio civil, la pericia es ordenada por el fiscal.
    - La pericia puede ser fijada por el fiscal a pedido de parte o puede hacerlo de oficio.
        - No se puede apelar lo que el fiscal rechaza.
- Con respecto a la denuncia, una vez que la víctima pide el auxilio de la fuerza pública, se insta a la acción. Solo el fiscal puede archivar la causa. El impulso es de oficio y el fiscal investiga, el juez controla (esto pasa en la provincia de Bs.As., es acusatoria)
- No existen peritos de lista, los peritos forman parte de las fuerzas de seguridad o del poder judicial.
    - La persona que lleva a cabo la pericia es un empleado del poder ejecutivo o judicial.
    - Estas pericias pueden mandarse a fuerzas federales (gendarmerías, fuerzas aeroportuarias, policía federal, etc.)
- Las partes pueden tener asesores técnicos (peritos de parte). Toda pericia debe ser notificada con una antelación de por lo menos 5 días. Esta notificación debe ser completa, si no se anula la pericia.

Pruebas informáticas

- Características

- Volátil: es muy fácil que la prueba se pierda o que el soporte se comprometa.
- Dispersa geográficamente: suele suceder cuando se trabaja con la nube, ya que la información esta diseminada por distintos países o se usan servidores de otros países (si la información se saca se infringe la soberanía). Esto implica la siguiente característica.
    - Necesaria de colaboración para su recolección:
        - Hay empresas sin oficinas en Argentina, por lo que se tiene que pedir a una oficia en Estados Unidos. Esto tarda mucho.
        - Puede pedirse digitalmente que tarde menos, pero la información es en los términos y condiciones de la plataforma a la que se pide. Si se quiere evitar esto ultimo conviene pedirla a la oficina, que se envía de la forma oficial.

- Límites a la recolección de la prueba en Art. 18 CN. (Inviolabilidad del Domicio, los papeles privados y sus comunicaciones)
    - La información depende de donde se obtiene:
        - Prueba en poder de la víctima: la suele dar voluntariamente.
        - Prueba en poder de un tercero:
            - Hay que diferenciar los datos de comunicación y datos de tráfico.
                - En muchos casos lo que se intenta averiguar es un ISP o IP. Esta es información de un tercero, que podría ser una violación al art. 18, pero como es un dato de tráfico, en realidad no se viola y puede solicitarse por oficio.
                - El articulo 18 protege los secretos de las comunicaciones (si se quiere solicitar esto se necesita orden), pero no el tráfico.
        - Prueba en poder del imputado
            - En principio no se puede acceder a nada, salvo que sea información en la que el imputado ya no tenga expectativa de privacidad (por ejemplo posteos).

- El objetivo de la actividad de campo es obtener prueba procedente, eficaz y procesalmente sostenible.
    - Procedente: la prueba sirve y es destinada para la hipótesis del fiscal.
    - Eficaz: tiene que llegar a un convencimiento
    - Procesalmente sostenible: una vez que yo la produzca no tiene que ser violatoria de los derechos constitucionales del imputado sino todo lo que se produce desde ese momento es nulo.

Buenas Prácticas de Obtención de Prueba Informática

- Actos preparatorios
    - Hay que conocer el lugar donde se allanara (informe policial con el numeral, descripción de la casa).
    - Establecer condiciones técnicas generales de los elementos a secuestrar.
        - Redes:
            - Establecer que tipo de red y seguridad tiene.
        - Características de los equipos a secuestrar.
            - Existen pericias que deben suceder en el lugar (por ejemplo, servidores, no se pueden secuestrar)
    - Establecer elementos a secuestrar: a veces los jueces en a duda secuestran cosas que no hacen faltas. Por ello hay que aclarar que secuestrar.
    - Elementos Básicos
        - Cámara fotográfica. Puede usarse un teléfono celular.
        - Guantes descartables.
        - Sobres papel madera, Cajas de cartón, adhesivo.
        - Documentos de cadena de custodia y fajas normalizadas.
            - Que es lo que se contiene, quien tomo la prueba, quien son los responsables, etc.

Lugar del Hecho

- Primero que todo, evitar romper.
- El perito debe esperar a que la situación sea segura.
- Se debe separar a todos los individuos que se encuentran operando algún equipo informático.

- Identificar individuos y vincular con las maquinas.
    - No se puede preguntar clave de acceso.
        - Si sucede el tipo esta declarando contra si mismo sin presencia de abogado y no es valido lo que se encuentre.
- Toda manipulación de material informático deberá ser realizado con guantes.
- Fotografías de todos los equipos encontrados antes de moverlos o desconectarlos.
    - Una toma panorámica de la habitación y una fotografía de cada uno de los sistemas informático.
    - En caso de que los equipos se encuentran encendidos, se deberá fotografiar la pantalla.
- En caso de inmuebles con más de una habitación deberán identificarse los distintos ambientes y los equipos se secuestraron en cada uno.
- Secuestrar toda la documentación.
- No hay que ver la información almacenada en las maquinas.

Secuestro del Material

- En caso de que los equipos informáticos se encuentren encendidos, se deben apagar los mismos en forma correcta.
    - Si los sistemas se encuentran encendidos destruyendo información el personal puede desenchufar.
- Secuestrar los dispositivos con los cables de alimentación o cargadores cuando corresponda según el dispositivo.
    - A su vez retirar la batería de alimentación cuando corresponda.
- Salvo instrucciones específicas, no resulta necesario secuestrar los siguientes elementos:
    - Dispositivos de entrada.
    - Parlantes.
    - Monitores.
    - Scanners e impresoras.
    - Grabadoras externas de DVD o CD.
    - Dispositivos de Red o Enlace.
    - Cables de red y alimentación del CPU.

    - CDs o DVDs que el sujeto tiene, no se le van a secuestrar todos, para que quieran uno de Taylor Swift.

Aseguramiento de Prueba

- Todo equipo informático secuestrado deberá ser precintado frente al testigo en todos sus puertos.
- En una computadores de escritorio, deberá colocarse como mínimo
    - Un precinto en la parte delantera que bloquee los puertos de entrada USB, lectoras y botón de encendido.
    - Un precinto en la parte posterior que cubra tanto las entradas de alimentación como los conectores de video, dispositivos de entrada y redes.
- En los dispositivos portátiles el precinto además de bloquear los conectores debe impedir el acceso a la conexión de la batería y apertura del sistema.
    - Es recomendable que cierren el dispositivo.
- Los precintos deberán ser colocados en forma tal que impidan su remoción (por esto es recomendable el uso de plasticola)
- Los precintos deberán ser mantenidos en forma inalterada.

Identificación de Prueba

- Todo el material secuestrado se identifica en el acta que debe ser firmado por todos los participantes de la diligencia.
- La CPU notebook, tablets, discos rígidos externos deberán ser identificados mediante su número de serie, modelo y marca.
- Todo teléfono celular deberá ser identificado mediante su número de IMEI.
    - Asimismo, debe consignarse el número de chip SMS y tarjeta de memoria si hubiere.
- Los dispositivos de almacenamiento óptico deben ser agrupados bultos de 25 unidades en sobre de papel identificados con numeración consecutiva.
- Si hay más de un ambiente aclarar la habitación de origen.
- Toda recolección debe realizarse usando el documento de cadena de custodia
    - Deberá usarse para cada elemento secuestrado, excepto donde los elementos se embalen juntos (ahí lo uso por caja duh).
        - Los elementos se meten en cajas.

    - Es recomendable que el sujeto verifique antes de firmar el documento los precintos y deje constancia de si están rotos.
- El traslado debe ser realizado por personal de procuración o personal policial autorizado, quienes deben firmar el documento de cadena de custodia al recibir los elementos.

Trabajo en laboratorio

- Todo equipo informático recibido debe estar precintado y acompañado por su cadena de custodia.
    - Si no sucede entonces el objeto no se recibe o se deja constancia.
- Toda manipulación deberá ser documentada por fotografías
- Para mantener la integridad de la prueba, nunca se debe trabajar sobre el soporte original.
    - Hay que elaborar una imagen forense (no hay que copiar archivos):
        - Es una copia idéntica bit a bit.
        - Luego esta imagen se monta en una máquina virtual.
        - Para realizar la imagen se copia con un bloqueador de escritura
            - Se puede utilizar uno por hardware o por software.
        - La imagen se obtiene utilizando un software forense informático
            - Encase
            - Guymager
            - FTK Imager